

1501286-17.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPÇÃO EM CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA PARA O CRIME DE TRÁFICO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE EXACERBADA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVADAS COM BASE NA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501286-17.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501286-17.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2135562/2022 - 09º D.P. GUARULHOS, 25054009 - 09º D.P.

GUARULHOS, 2135562 - 09º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ÉVERTON GONÇALVES PAIXÃO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

ÉVERTON GONÇALVES PAIXÃO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 caput, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia no dia 18 de maio de 2022, por volta de 12h00min, na Rua Maria José Alves, 120, Taboão, nesta cidade e comarca de Guarulhos, em concurso com o adolescente Matheus de Lima Nascimento dos Santos, traziam consigo, para fins de tráfico, 57 porções de crack, com massa líquida de 11 gramas, 64 porções de maconha, com massa líquida de 131,4 gramas e 196 porções de cocaína, com massa líquida de 108,3 gramas, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo de constatação provisória de fls. 49/54) (fls. 61/62). Acompanha a denúncia o inquérito policial (01/56).

Devidamente notificado (fl. 74), o acusado apresentou defesa preliminar, com rol de testemunhas comuns (fls. 77/80).

A denúncia foi recebida em 22 de agosto de 2022 (fls. 86/88).

Nesta data, na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas comuns. Em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Ao final, as partes apresentaram alegações finais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 04/07), auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), laudo de constatação provisória (fls. 27/32 e fls. 49/54), exame químico-toxicológico - laudo definitivo (fls. 97/99), dando conta de que as substâncias apreendidas tratavam-se de COCAÍNA e TETRAHIDROCANNABINOL (THC), bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria também é segura e aponta para o acusado, senão vejamos.

O acusado ÉVERTON GONÇALVES PAIXÃO, em solo policial, disse que não trabalha no tráfico de drogas, é apenas usuário de drogas e morador de rua. Que nega terminantemente estar hoje "...trabalhando" como campana (fl. 21). Em juízo, confessou a prática delitiva. Informou que foi até o local para comprar drogas. Como não tinha dinheiro, o rapaz lhe ofereceu uma pedra de crack para ficar ali meio período na condição de olheiro. Já foi processado por tráfico de drogas. Estava morando na rua há oito anos.

A confissão do acusado foi corroborada pelas demais provas colhidas na fase judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

Os policiais civis JOSÉ AGUIBSON SOARES DA SILVA, ANDRÉ RAMOS PINTO e EMERSON GOULARTE GASPARI, em solo policial, em depoimentos semelhantes, narraram que que no desenvolver de seus expedientes ao combate do Tráfico de Drogas que assolam nossa circunscrição, mais uma vez investiu tempo e energia sobre um conhecido ponto de venda de drogas conhecido como "Biqueira do Murão"; que desta sorte, o depoente e seus colegas, conhecedores daquele local, instalaram uma observação velada, da qual puderam visualizar as pessoas de MATHEUS DE LIMA NASCIMENTO DOS SANTOS, RG: 65.884.479, como também a pessoa de EVERTON GONÇALVES PAIXÃO, RG:62.14.31, ambos na promoção do tráfico de drogas ilícitas, onde MATHEUS ocupava a função de sacola, e EVERTON a função de campana; que ali os dois se achavam adotando posturas vigilantes e apreensivas. E no decorrer desta observação os policiais puderam observar que em duas oportunidades distintas, supostos usuários e pretensos compradores, trocavam breves palavras com a pessoa de EVERTON, o qual ali realizava uma breve entrevista em triagem, e depois de satisfeito, autorizava a passagem daqueles até Matheus, que efetivamente realizava a tradição de compra e venda; que visto isso, o depoente e seus colegas decidiram por agir, e se valendo do conhecimento topográfico do local, se dividiram a ajustar uma infiltração mais eficaz naquele sítio, de modo que, cada policial percorreria as prováveis rotas de fuga a ser utilizada por aqueles que ali se achassem na promoção da traficância. E assim se deu, quando da tomada daquele ambiente pela Equipe-A, o policial AGUIBSON foi na dianteira se passando por usuário, conseguindo passar por EVERTON e chegar até a pessoa de MATHEUS. E quando do alcance de MATHEUS, o depoente decidiu pela abordagem, surpreendendo e contendo o menor infrator com o apoio do POLICIAL André. Ato contínuo, EVERTON, desenfreado, empreendeu breve fuga, indo de encontro ao policial EMERSON, onde foi abordado e contido; que agora com a situação controlada e pacificada, e com os policiais reagrupados, sobre os indiciados foram precedida uma busca pessoal, da qual nada de ilícito foi encontrado com EVERTON. Conquanto, MATHEUS ostentava em suas mãos uma sacola plástica contendo considerável quantidade de drogas ilícitas, todas já fracionadas em porções ideais a mercancia espúria,

quais sejam 57 porções de crack acondicionadas em eppendorfs, 64 porções de maconha acondicionadas em saquinhos plásticos, 146 porções de cocaína acondicionadas em eppendorfs, e 50 porções de cocaína acondicionadas em plásticos hermeticamente selados. E tinha também em seu bolso a quantidade de R\$580,00 em notas trocadas; que perguntado ainda no local a EVERTON e Matheus sobre as drogas e o dinheiro ali apreendidos, ambos assumem a traficância, sendo MATHEUS o "sacola" e EVERTON o "campana"; que quando perguntado a eles quem os haveria cooptado para aquele trabalho, ambos não quiseram ou não souberam responder (fls.14/15, fls.16/17 e fls.18/19).

O policial civil ANDRÉ RAMOS PINTO, em juízo, afirmou que a equipe se dirigiu a uma comunidade dominada pelo tráfico de drogas, ponto conhecido como Biqueira do murão. No local fizeram campana por cerca de 15 a 20 minutos. O réu estava separada do menor numa distância de 15 a 20 metros. Durante a campana presenciaram dois usuários comprando drogas. Eles se aproximavam do ponto, falavam com o réu e depois se dirigiam ao adolescente, que trazia uma sacola na mão, e com quem compravam o entorpecente. Confirmado o tráfico, resolveram abordar os indivíduos, sendo que se separaram em três entradas distintas, tentando cobrir possíveis rotas de fuga. Ficou escondido no mato, enquanto o policial José Aguibson se aproximou dos agentes e o policial Emerson ficou na rota que dava para um escadão. O policial José Aguibson passou pelo acusado e depois se dirigiu ao menor. Como estava escondido no mato, cobrindo uma das rotas de fuga, não conseguiu ver se José Aguibson trocou alguma palavra com o acusado. Assim que chegou próximo do adolescente, o policial Josep Aguibson já o abordou, se identificando como policial. Saiu de onde estava e prestou apoio ao seu colega. O acusado ao perceber a presença da polícia, saiu correndo e gritou "moiou, moiou". Como correu na direção onde estava o policial Emerson, foi por ele abordado. Com o acusado nada foi encontrado. Já com o menor foi encontrada a sacola plástica, dentro da qual havia entorpecentes e dinheiro. Questionados, o menor assumiu ser o "sacola", pessoa que fica com a sacola de drogas e é responsável pela venda do entorpecente, enquanto o réu disse ser o "antena", pessoa que faz fazia a função de campana e avisa da chegada da polícia e qualquer pessoa estranha. Afirmou que durante a campana viu que era o acusado quem recepcionava os supostos usuários, com eles trocava alguma palavra e os direcionava para o menor..

No mesmo sentido, foi o depoimento do policial civil JOSÉ AGUIBSON SOARES DA SILVA, o qual relatou que no dia realizaram campana em uma comunidade onde há um conhecido ponto de tráfico, chamado de biqueira do Murão. Durante a campana, visualizaram o réu e um adolescente realizando o tráfico, em nítida divisão de tarefas. O réu fazia a função de "pano", "campana", responsável por fazer a triagem dos supostos usuários, pois conversa com a pessoa, faz revista e autoriza seu acesso ao "sacola", que era o adolescente, o qual possuía os entorpecentes. Durante a campana, viram claramente a aproximação de dois supostos usuários, que primeiro conversavam com o réu e em seguida iam até o adolescente, fazendo a tradição drogas/dinheiro. Constatado o tráfico, se aproximou do ponto, fingindo ser usuário. Falou com o réu, se valendo de jargão típico de usuário, e teve por ele o acesso liberado ao adolescente, que estava com os entorpecentes. Lá chegando, deu voz de prisão e notou que o réu tentou se evadir, gritando "moiou", para visar sobre a presença da polícia no local. O réu foi abordado por seu parceiro Emerson que estava posicionado em uma das possíveis rotas de fuga. Com o réu nada de ilícito foi encontrado. Com o menor apreendera uma sacola com drogas e dinheiro. Questionado, o réu admitiu que estava na função de "pano", alegando que recebia seu pagamento drogas para sustentar seu vício.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

"PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob

juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

"PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido." (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, STJ, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

"Apelações - Tráfico de drogas - Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos - Pedido de absolvição por falta de provas - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Corréus que apresentaram versões contraditórias, rechaçadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, uníssonos durante toda a persecução penal - Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade (...)" (Apelação nº 0000179-03.2017.8.26.0530, TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Juscelino Batista, j. 20.05.2021).

Pois bem, diante da confissão do acusado, acrescida dos depoimentos seguros e harmônicos dos policiais ouvidos na fase policial e em juízo, é de se reconhecer que restou demonstrado, à saciedade, que EVERTON, em concurso com o adolescente Matheus de Lima Nascimento dos Santos, traziam consigo, para fins de tráfico, os entorpecentes apreendidos, não prevalecendo a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória.

Não há qualquer razão para duvidar dos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, os quais não conheciam os acusados e, portanto, não teriam motivos para atribuir-lhes falsamente a prática de crime tão grave, não tendo a defesa trazido qualquer dado concreto que faça concluir pelo contrário, até porque o próprio réu admitiu a posse das drogas na ocasião.

Além da certeza quanto ao envolvimento do acusado com o entorpecente apreendido, também não há dúvidas de que as substâncias destinavam-se ao tráfico, diante da variedade e quantidade de droga (57 porções de crack, com massa líquida de 11 gramas, 64 porções de maconha, com massa líquida de 131,4 gramas e 196 porções de cocaína, com massa líquida de 108,3 gramas), da forma como estavam embaladas e separadas, das circunstâncias que envolveram a prisão, após breve campanha policial, tentativa de fuga e apreensão de quantia em dinheiro e anotações de venda.

Insta consignar ainda que o delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, possui tipo multinuclear ou de ação múltipla, visto que a prática de quaisquer dos verbos nucleares do tipo é suficiente para a consumação do delito.

Oportuno lembrar que: "o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou núcleos do tipo, em face do que tal delito se consuma com a prática de qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativo" (STJ; HC 27704/MS; Sexta Turma; Min. Rel. Hamilton Carvalhido; J. em 09/05/2006).

Na mesma linha, é o entendimento recente:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO

DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA_BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. DELITO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E DE IGREJA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive trazer consigo, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. (...) 8. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 1846368/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) (Grifei).

E ainda: "considera-se consumado o tráfico quando evidenciada o estado de flagrância em quaisquer de seus núcleos, ou seja, no momento da importação ou exportação, do depósito ou do transporte, de trazer consigo ou da guarda do entorpecente." (STJ; HC 34374/MS, Min. Gilson Dipp; Quinta Turma; DJ 01/07/2004) (Grifei).

Presente, ainda, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI da Lei n.º 11.343/06, uma vez que a prova colhida também evidencia que o acusado praticou o tráfico com o envolvimento do menor Matheus de Lima Nascimento dos Santos, tudo a evidenciar sua colaboração com a conduta praticada pelo acusado e, portanto, com a configuração da causa de aumento de pena acima mencionada.

O fato do menor já estar ou não corrompido, não afasta a majorante.

Por fim saliento que embora não fosse o acusado quem estivesse em poder do entorpecente e fosse o responsável direto pela venda do entorpecente, bem como que ele tenha dito que sua função era de "campana", não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no artigo 37 da Lei 11343/06 como sustentado pela defesa, uma vez que conforme evidenciado na instrução pelas depoimentos dos policiais, sua função não era apenas de "colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de tráfico", mas sim prestar efetivo auxílio da venda da droga realizado pelo adolescente, eis que ficava no ponto de venda, recepcionando os usuários, portanto, responsável pela triagem, e era a pessoa responsável por autorizar a passagens dos usuários e aproximação destes até o menor, conduta que ultrapassa, e muito, a mera colaboração como informante.

Desta feita, provada a materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seus comportamentos, é de rigor a condenação do acusado Everton, nos exatos termos da denúncia, até porque as teses fáticas levantadas pelas Defesas em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na aplicação das penas, levando em conta as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, observo que a considerável quantidade de entorpecente apreendidos (57 porções de crack, com massa líquida de 11 gramas, 64 porções de maconha, com massa líquida de 131,4 gramas e 196 porções de cocaína, com massa líquida de 108,3 gramas), a variedade e natureza da droga apreendida, sendo parte delas de elevada nocividade e alto poder viciante (cocaína e crack), autorizam o aumento da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei de Tóxicos. Assim, acresço a pena-base de 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nesse mesmo sentido, abarca a jurisprudência:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO

MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA. ENTORPECENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente lastreada na quantidade e natureza do entorpecente encontrado em poder do réu - pasta-base de cocaína, de alto poder deletério -, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o que afasta a alegação de fundamentação inidônea. 2. Agravo desprovido." (AgRg no REsp 1793804/MT, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (Grifei);

"5. De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 6. Hipótese em que as instâncias antecedentes, atentas às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, consideraram a natureza da droga apreendida (cocaína) para fixar a pena-base acima do mínimo legalmente previsto. [...] 11. Habeas corpus não conhecido" (HC 461.769/MS, de minha relatoria, STJ, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) (Grifei).

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/2006. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se reconhece o alegado constrangimento ilegal se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal devido à quantidade e qualidade da droga apreendida - 2.600g (dois mil e seiscentos gramas) de cocaína - conforme o que preceitua o artigo 42 da Lei nº 11.343/06. 2. Agravo regimental a que se nega provimento". (AgRg no HC 177.241/RJ, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 15/06/2011).

Na segunda fase da pena, presentes as atenuantes da confissão e da menoridade relativa. Presente, por outro lado, a agravante da reincidência, que foi recepcionada pela Constituição Federal por servir como mecanismo de aplicação do princípio da individualização das penas, pois o réu ostenta uma condenação definitiva, transitada em julgado, em data anterior aos fatos ora apurados, pelo delito de tráfico de drogas (processo n.º 1500117-67.2020.8.26.0372, da 1ª Vara do Foro de Monte Mor - processo de execução da pena n.º 0012185-24.2020.8.26.0502, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 33/34 e F.A. de fls. 36/37 e fls. 103/106) sendo, portanto, reincidente específico. Assim, enquanto uma das atenuantes serve para compensar com a agravante da reincidência, a outra justifica a redução das penas, razão pela qual retorno as penas ao mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Na derradeira etapa, ausentes causas de diminuição de pena. Presente, por outro lado, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06, razão pela qual aumento as penas de 1/6 (um sexto), fixando-as, em definitivo, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Observo que, em face da reincidência, fica afastada a causa de diminuição de pena tipificada no artigo 33, §4º da Lei n.º 11.343/06. Não há que se falar em bis in idem mormente porque, para incidência da referida causa de diminuição, faz-se necessário que o réu seja primário, o que não se verifica no caso em análise. Esse é o forte posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPÇÃO EM CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA PARA O CRIME DE TRÁFICO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE EXACERBADA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVADAS COM BASE NA EXPRESSIVA QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA DE DOIS DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONDUTA QUE EXTRAPOLOU À

INERENTE AO TIPO PENAL VIOLADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. CONSIDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA E TERCEIRA FASES QUE NÃO ENSEJA BIS IN IDEM. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO DETERMINADO EM FUNÇÃO DO MONTANTE DA REPRIMENDA IMPOSTA. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. - A reincidência do paciente constitui óbice suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, haja vista não estar preenchido o requisito legal da primariedade. Precedentes. - Ademais, a orientação desta Corte de Justiça é no sentido de que o reconhecimento da reincidência do réu é elemento suficiente para impedir a aplicação do redutor, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. Precedentes. (...)” (AgRg no HC 630.337/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) (Grifei);

“(...) 5. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 6. Reconhecida a reincidência do agente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. A utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. Precedentes. (...) 8. Habeas corpus não conhecido”. (STJ HC 427.620/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 15.03.2018, DJe 20.03.2018 g.n.).

O valor do dia-multa, ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no seu valor unitário mínimo, devidamente atualizado, conforme o prescrito no artigo 38 e seus parágrafos da Lei 6368/76. (O art. 38 da Lei Antitóxicos não foi derogado pela reforma penal de 1984 - TJSP, Tacrim 147.227, Rel. Des. Dante Busana, JTJ, 150/288).

Diante da quantidade da pena imposta e reincidência do agente, incabível a concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em se tratando de delito equiparado a hediondo, o regime inicial para o cumprimento de pena para o acusado é o FECHADO, justificável não só ante a latente gravidade do crime, fomentador de tantas outras práticas ilícitas como também pelo fato de os demais regimes não se mostrarem adequados para a ressocialização do réu, além de serem incompatíveis com sua reincidência específica, demonstrando dedicação à prática delitiva, evidenciando que a medida de reclusão pretérita não surtiu o devido efeito.

Deveras, não se mostra adequado, in casu, regime mais brando, afigurando-se oportuno citar, a respeito as seguintes jurisprudências:

“TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO SUBSIDIÁRIO - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO INADMISSIBILIDADE - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 11.464/2007. “Ressalto que há determinação expressa no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, de que as penas por crime hediondo ou equiparado iniciam-se no regime fechado”. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ/SP. AP 0057527-71.2011.8.26.0050. Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Marco Antonio Marques da Silva. Data do julgamento: 27/06/2013).

Ademais, ainda que a Lei nº 12.736/12, que alterou a redação do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, preveja o cômputo da prisão provisória, uma vez fixado o regime inicial de cumprimento de pena a partir dos critérios de individualização, a

análise dos elementos objetivos e subjetivos, que dizem com a progressão, estranhos a este juízo de conhecimento, são de competência do juízo das execuções criminais, não prosperando a análise, neste momento.

No mais, considerando-se a gravidade do delito cometido, o regime de pena imposto por lei, o fato do acusado ser reincidente específico e ter permanecido preso durante todo o processo, não poderá recorrer em liberdade, afora tratar-se de imposição legal, nos moldes do artigo 44 da Lei nº. 11.343/06. O contexto fático no qual foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não se alterou. É dizer, os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a cautelar restrição da liberdade do réu subsistem. Ficam inclusive reforçados com a condenação. Ainda assim, diante das condições subjetivas e a quantidade de pena aplicada ao acusado faz submergir a necessidade de segregação para resguardar a ordem pública e garantir a futura aplicação da lei penal.

No sentido exposto, Julio Fabrin Mirabete (Código de Processo Penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), in verbis: "O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituesa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional".

Ainda, no entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública, enquanto um dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, temos que: "Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social." (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT, 2007, 6ª ed, p. 590).

Por fim, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar Maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (HC 550.211/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR EVERTON GONÇALVES PAIXÃO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33 caput, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, c/c o artigo 61, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento de 5 (CINCO) ANOS e 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, além do pagamento de 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

O réu não poderá apelar em liberdade.

Recomende-se o réu no local onde estiver preso.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais. Defiro ao acusado os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Insta consignar que cobrança da taxa estará extinta decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que o acusado tem condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, §3º, do C.P.C..

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;

2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 27 de setembro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA